



CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione IV civile

R.G. 5636/2018

All'udienza collegiale del giorno 02/11/2023 ore 12:30

dott. Giovanni Buonomo

presidente

dott. Giovanna Schipani

consigliere

dott. Francesca Della Valle

consigliere relatore

Con l'assistenza del sottoscritto funzionario

Chiamata la causa

Appellante/i

Parte_1

[...]

Avv. VINTI STEFANO sostituito dall'avv. FEDERICA CORSINI

Avv. OTTANI MICHELE

Appellato/i

CP_1

Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO procuratore dello stato

CP_2

[...]

È altresì presente ai soli fini della pratica professionale forense il praticante procuratore dott.

Controparte_3 tessera numero P78126, Ordine Avvocati di Roma.

È altresì presente ai soli fini della pratica professionale forense il praticante procuratore dott.

CP_4 tessera numero *Num_1* Ordine Avvocati di Roma

Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c.

L'avvocato CORSINI discute oralmente la causa riportandosi alle considerazioni e alle conclusioni rassegnate nel proprio atto di appello; allega sentenza del CdS 513/2022 a sostegno delle tesi sostenute nell'atto di appello e chiede la restituzione di quanto anticipato in esecuzione provvisoria della sentenza impugnata.

Il procuratore dello stato discute oralmente la causa riportandosi alle considerazioni e alle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta.

La Corte

decide con sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.

IL FUNZIONARIO

Lucrezia Manganelli

IL PRESIDENTE

Giovanni Buonomo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dott. Giovanni Buonomo	Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani	Consigliere
- dott.ssa Francesca Della Valle	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(artt. 352, comma 6, e 281-*sexies* c.p.c.)

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5636 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 decisa all'udienza del 2.11.2023 e vertente

TRA

Parte_1	p.iva	P.IVA_1	)
Parte_1	(c.f.	P.IVA_2	)
Parte_1	(c.f.	P.IVA_3	)
Parte_1	(c.f.	P.IVA_4	)

tutte rappresentate e difese per mandato in calce all'atto di appello dall'avv. Michele Ottani (c.f. C.F._1) e dall'avv. Stefano Vinti (c.f. C.F._2);

- PARTI APPELLANTI -

E

CP_1 (c.f. e P.IVA P.IVA_5), rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Musti (c.f. C.F._3) e Ilaria Ciccotti (c.f. C.F._4) giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- PARTE APPELLATA -

OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 13666 pubblicata il 3.7.2018 (opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto).

FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

§ 1. – Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_1 Parte_1 hanno proposto appello avverso la sentenza n. 13666/2018 con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione da loro avanzata contro il decreto ingiuntivo n. 5168/2015 dell'importo di € 700.000,00 (oltre a interessi di mora al tasso legale dal 16.5.2012 al saldo) nonché spese della procedura di ingiunzione e rimborso delle spese generali, in favore delle CP_1 quale cauzione versata dalle ingiunte con la polizza fideiussoria a prima richiesta n. 01601110202134 rilasciata dalla Pt_1 Org_1 il 28.10.2010 per la partecipazione alla gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di facility management per immobili adibiti ad uso ufficio in uso alle pubbliche amministrazioni, indetta dalla ingiungente relativamente al lotto n. 3, condannando le stesse alle spese di lite.

A sostegno dell'appello hanno formulato due motivi, chiedendo accertarsi e dichiararsi «il difetto di legittimazione passiva delle imprese appellanti e/o l'intervenuta scadenza ed estinzione e/o l'avvenuto svincolo e/o l'avvenuta rinuncia alla cauzione provvisoria [...] accertarsi e dichiararsi di conseguenza l'assoluta inesigibilità della garanzia medesima anche nei confronti delle imprese ingiunte», con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio a carico della società convenuta, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..

§ 2. – Si è costituita la parte appellata, che ha contestato la fondatezza dell'appello, instando per il suo rigetto.

§ 3. – All'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

§ 1. – Con il primo motivo di appello, articolato su diversi profili, dalle imprese ingiunte viene contestato che il giudice avrebbe erroneamente deciso in ordine, da un lato, al lamentato difetto di legittimazione passiva e, dall'altro lato, alla contestata intervenuta rinuncia e scadenza.

§ 2. – Quanto al primo profilo relativo al difetto di legittimazione, le appellanti sostengono che, stante la natura di contratto autonomo di garanzia della polizza, esse non potrebbero essere destinatarie dell'obbligo di pagamento della polizza, posta a fondamento della richiesta monitoria, in quanto non si porrebbe in capo a loro un obbligo di pagamento identico a quello del garante. CP_1, infatti, nei loro confronti avrebbe potuto azionare unicamente un'azione risarcitoria per responsabilità precontrattuale.

§ 2.1. – Il motivo, sotto questo profilo, deve reputarsi infondato.

Deve convenirsi per la natura di contratto autonomo di garanzia, sostenuta dalle appellanti, come stabilito anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 3947/2010, secondo la quale *«[l]a polizza fideiussoria prestata a garanzia dell'obbligazione dell'appaltatore costituisce una garanzia atipica in quanto, non potendo garantire l'adempimento di detta obbligazione, perché connotata dal carattere dell'insostituibilità, può semplicemente assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento, risultando, quindi, estranea all'ambito delle garanzie di tipo satisfattorio proprie delle prestazioni fungibili ed essendo, invece, riconducibile alla figura della garanzia di tipo indennitario in forza della quale il garante è tenuto soltanto a indennizzare, o a risarcire, il creditore insoddisfatto... L'inserimento in un contratto di assicurazione fideiussoria di una clausola "a semplice richiesta" o "senza eccezioni" vale di per sé a trasformare la polizza in un contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione»*.

D'altronde, l'art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006, nel disporre l'obbligo di prestazione di una garanzia pari al 2% a corredo dell'offerta, richiede espressamente che la garanzia preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

E però, anche a ritenere corretta la qualifica di contratto autonomo di garanzia nella fattispecie in esame, deve ritenersi che strutturalmente permane l'accessorietà e la solidarietà delle obbligazioni del garante e del garantito.

Una diversa lettura sarebbe contrasto con la *ratio* della garanzia di tutela della PA sottesa alla disciplina dell'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006, che è, per la cauzione provvisoria, quella di garantire la serietà e affidabilità dell'offerta fino al momento della stipula del contratto (Cass., SS.UU., n. 2634/2009; Cons. Stato, Ad. plen., n. 34/2014 nonché Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 10 ottobre 2012, par. 5). Tale finalità è rafforzata dall'espressa previsione che la garanzia debba prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di art. 1957, secondo comma, c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima a semplice richiesta della stazione appaltante.

Ritenere che la prestazione della garanzia liberi il garante finirebbe, invece, per tradurre tale strumento – chiaramente ispirato al *favor creditoris* – in uno svantaggio per il creditore (che potrebbe procedere all'escussione nei confronti del solo garante).

Inoltre, diversamente ragionando, posto che l'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 lascia all'offerente la scelta tra la garanzia sotto forma di cauzione (in contanti o in titoli) o di fideiussione, sarebbe a lui rimessa la scelta del tutto libera di optare per quest'ultima e in tal modo – stante l'assenza di solidarietà tra debitore e garante – di liberarsi da qualsiasi obbligo.

Deve quindi reputarsi che la speciale figura di garanzia provvisoria prevista dall'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 vincoli tanto il garante quanto il garantito.

A conferma della correttezza di tale lettura depone, altresì, un'ulteriore significativa circostanza, ovverosia l'omogeneità delle obbligazioni facenti capo alla garante e alla garantita. L'art. 1 dell'“Atto di fideiussione – garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria” prevede, infatti, che “il Garante si impegna nei confronti delle Stazione appaltante, fino alla concorrenza della somma garantita, al pagamento delle somme dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara di cui alla Scheda Tecnica” (doc. 3 fascicolo I grado Pt_1). E ciò contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, le quali sostengono la natura "differente e alternativa" dell'obbligazione in capo a loro (di diligenza e serietà precontrattuale) rispetto all'obbligazione del garante (di provvedere al pagamento della somma garantita).

Né vale, a inficiare il ragionamento sin qui svolto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 513/2022, prodotta da parte appellante all'odierna udienza, trattandosi di giurisprudenza non conferente al caso di specie, relativa alla diversa ipotesi in cui la stazione appaltante non si avvalga del diritto di escutere la garanzia ovvero se ne avvalga tardivamente, in tal modo perdendo la posizione di vantaggio assicurata dallo speciale strumento normativo.

§ 3. – Ugualmente infondato è il motivo di appello con riferimento all'ulteriore profilo della presunta intervenuta rinuncia e scadenza della polizza.

§ 3.1. – Risulta dagli atti che la CP_1 , con nota prot. n. 36301/2011 del 16.12.2011, comunicò di aver proceduto, ai sensi del disciplinare di gara, a verifiche d'ufficio ex art. 71 D.P.R. n. 445/2000 relativamente alle dichiarazioni rese dal costituendo ^{Contr} e di aver accertato, con riferimento alla società [...]

Organizzazione_2 che era stata emessa una sentenza penale irrevocabile risultante dal certificato del casellario giudiziale rilasciato il 10.11.2011 nei confronti del legale rappresentante, a fronte della dichiarazione

sostitutiva resa da quest'ultimo di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163/2006.

Conseguentemente, la CP_1, con comunicazione ex art. 79, comma 5, d.lgs. n. 163/2006, prot. n. 4971/2012 del 23.2.2012, dispose l'esclusione del CP_6 [...] Parte_1 Parte_1 e Parte_1 dalla gara in oggetto con riferimento ai lotti 3 e 6. In tale comunicazione – come ammesso dalle stesse appellanti – si riservò espressamente di provvedere all'escussione della polizza. All'esito dei gradi del giudizio amministrativo relativi all'impugnazione del provvedimento di esclusione – respinta, dapprima, dal TAR con sentenza n. 9166/2012 e, poi, dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2176/2013 – la CP_1 agì, dunque, in sede monitoria per l'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 48 d.lgs. n. 163/2006, applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, dopo l'esclusione delle odierne oppositori dalla gara d'appalto sopra descritta per causa a loro imputabile.

Stante la espressa riserva di provvedere all'escussione della garanzia nel provvedimento di esclusione del RTI, non può ritenersi che la stessa sia stata superata dalla intervenuta aggiudicazione della gara in data 21.12.2012 ad altro soggetto, né dalla restituzione dell'originale della cauzione provvisoria avvenuto con prot. n. 40327 del 27.12.2012; e ciò in quanto, in presenza della espressa riserva di procedere all'escussione, non può attribuirsi valore liberatorio alla mera restituzione degli originali della polizza priva di ulteriori manifestazioni di volontà.

La disciplina dell'art. 3 (svincolo della garanzia) richiamata dalle appellanti – secondo la quale “la stazione appaltante nell'atto in cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia” – riguarda, naturalmente, la fisiologica ipotesi in cui a seguito dell'aggiudicazione a favore di uno dei concorrenti venga disposto lo svincolo della garanzia per tutti gli altri concorrenti non aggiudicatari adempienti rispetto agli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara. Tale svincolo contestuale ed automatico non può di certo, dunque, realizzarsi nell'ipotesi di inadempimento a tali obblighi, posto che la garanzia è tesa proprio a coprire tale ipotesi di inadempimento. Senza contare, poi, che la CP_1 aveva formalizzato espressa riserva di escussione.

Il motivo deve reputarsi infondato con riferimento a questo profilo.

§ 3.2. – Ugualmente infondato è l'ulteriore profilo relativo alla presunta tardività dell'escussione da parte della CP_1.

Per quanto risulta dagli atti la polizza in esame è stata rilasciata con scadenza iniziale fissata al 5.8.2011 e prorogata – come esposto dalle stesse appellanti – sino al 28.2.2012 al fine di garantire la conclusione della procedura. Secondo quanto previsto dal codice degli appalti, la polizza fideiussoria stipulata a garanzia dell'offerta è, infatti, soggetta ad un termine, al sopraggiungere del quale, se ancora non sia intervenuta l'aggiudicazione, la stazione appaltante deve richiedere al garante l'estensione temporale della garanzia e, nel caso in cui la stazione appaltante non si sia avvalsa di tale potere, la garanzia cessa alla scadenza stabilita nel contratto.

Ebbene, come sopra ricordato, prima della scadenza del termine di durata, in data 23.2.2012, la CP_1 comunicò alle appellanti l'intenzione di provvedere

all'escussione della polizza, con comunicazione ex art. 79, comma 5, d.lgs. n. 163/2006.

Ciò premesso, va ritenuto, come già correttamente affermato nella sentenza di primo grado, che il termine relativo alla validità della garanzia è diverso dal termine decadenziale entro il quale poter procedere all'escussione, che è invece disciplinato dal termine di prescrizione del relativo diritto.

§ 4. – Con il secondo motivo di appello, infine, viene sostenuta l'imputabilità della esclusione dalla gara alla responsabilità delle imprese appellanti.

Tale motivo è inammissibile in quanto riguarda la illegittimità del provvedimento di esclusione, già oggetto dei due gradi di giudizio innanzi al giudice amministrativo, che ha rigettato il ricorso con sentenza ormai definitiva.

§ 5. – In definitiva, l'appello va respinto.

Le appellanti vanno condannate al pagamento delle spese di questo giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, che si liquidano utilizzando i parametri di cui D.M. n. 55/2014 (modificato, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022), con riferimento allo scaglione compreso tra € 520.001,00 e € 1.000.000,00, valori medi, in complessivi € 18.511,00 per compensi (di cui € 5.706,00 per fase di studio; € 3.318,00 per fase introduttiva; € 9.487,00 per fase decisionale; esclusa la fase di trattazione/istruttoria, perché non svoltasi – cfr. Cass. ord. 16.4.2021 n. 10206).

Poiché l'appello è stato proposto in data successiva al 30 gennaio 2013 ed è respinto integralmente, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19554/2018 pubblicata il 12.10.2018, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1. – rigetta l'appello;

2. – condanna, in solido tra loro, Parte_1

[...] Parte_1 Parte_1 e Parte_1 a rifondere le spese di questo giudizio a CP_1 che liquida in € 18.511,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, Iva e Cpa, come per legge;

3. – dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Roma il 2.11.2023

Il Consigliere est.

- dott.sa Francesca Della Valle -

Il Presidente

- dott. Giovanni Buonomo -